



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 214/12
מס' בקשה: 98/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

המבקש: מתתיהו דוידוביץ
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד רז זנו
מרחוב המלך ג'ורג' 35 ירושלים

נ ג ד

המשיבים: 1. חיים גמליאל
הנתבעים: 2. חנה גמליאל
ע"י ב"כ עוה"ד שחר עוז-ארי
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם בעלי זכויות בדירות בבית ברחוב כתריאל טחורש 7 בירושלים הבנוי על חלקה 252 בגוש 30338 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

המבקש עתר בבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד לפיו ייאסר על הנתבע לבצע כל פעולה בקיר הבית המשותף הסמוך לפתח דירתו. המבקש טען בבקשתו כי המשיב 1, שהינו אדם מוגבל פיזית, מבקש לפתוח פתח נוסף אל דירתו בקיר המשותף ללא קבלת הסכמה של איש מבעלי הדירות. אומנם, נתקבל בידי המשיבים היתר בניה לצורך פתיחת הפתח. אולם, מן הבחינה הקניינית פתיחת הפתח אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 59ג לחוק המקרקעין, שכן למבקש יגרם נזק בלתי סביר בשל העבודות המתוכננות ובכלל האמור לא נשקלו חלופות אחרות לביצוע ההתאמות הנדרשות למשיב.

בהחלטתי מיום 23.07.12 נתתי צו מניעה זמני כמבוקש, הורתי על הגשת תביעה ותשובה לבקשה וקבעתי מועד לדיון בבקשה. כן הורתי למבקש להמציא את הבקשה ואת צו המניעה במסירה אישית למשיבים בתוך 48 שעות.

בתשובתם לבקשה טענו המשיבים כי עוד בטרם נמסר צו המניעה לידם כבר נפתח פתח הכניסה לדירה שמניעתו התבקשה בהליך דנן. לגופם של דברים טענו המשיבים כי הם פעלו בהתאם להוראות סעיף 59ג לחוק המקרקעין ופעולתם חוקית בעוד התביעה דנן חורגת מהוראות הדין, כי הטענות התכנוניות של המבקש נדחו ע"י הרשויות המוסמכות ואין לדון בהן בהליך זה, כי האלטרנטיבות המוצעות נבחנו ונשללו על ידי אנשי מקצוע ואין כל פגיעה במבקש. עוד נטען כי בידי המשיבים הסכמה של 7 מתוך 10 בעלי דירות בבית לביצוע העבודות.

ביום 31.07.12 נערך דיון בבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 214/12
מס' בקשה: 98/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לאור העובדה כי עד למועד מסירת צו המניעה כבר נפתח הפתח בקיר, נתבקשתי בדיון מיום 31.07.12 להתיר למבקש לשנות את הסעד בבקשה לצו עשה זמני לסגירת הפתח שנפתח. בהקשר זה נטען על ידי המבקש כי עילת הבקשה נותרה זהה וכל שנדרש הוא שינוי של הסעד המבוקש, רק לאור העובדה כי, בין מועד מתן הצו ועד למועד מסירתו, הזדרזו המשיבים וביצעו את העבודות נשוא המחלוקת דנן.

המשיבים התנגדו לבקשה לשינוי הסעד בטענה כי מלכתחילה לא היה מקום להגשת הבקשה והתובענה שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות החוק.

דיון

לאור העובדה שאיננה שנויה במחלוקת כי צו המניעה נמסר למשיבים לאחר ביצוע העבודות על ידם, אין עוד מקום להותרתו של צו המניעה שניתן ביום 23.07.12 על כנו ואני מורה על ביטולו.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בדיון בפני, ובנסיבות שנוצרו לפיהן, על אף צו המניעה שניתן, העבודות בוצעו טרם מסירתו של הצו למשיבים, אני מקבל את בקשת המבקש לשנות את הסעד בבקשה כאילו נתבקש צו עשה זמני להחזרת המצב לקדמותו.

בהקשר זה אעיר כי טיעוני המשיבים בהתנגדותם לבקשה זו היו טיעונים לגופם של דברים, בין אם המדובר בצו מניעה זמני ובין אם המדובר בצו עשה זמני. בנסיבות אלו מוצא אני לנכון ליתן הכרעה לגופם של דברים ולא לדחות את הבקשה אך בשל הנסיבות שנוצרו כאמור לעיל. ויודגש, דחיית הבקשה מהסיבה האמורה לא תמנע הגשת בקשה נוספת על ידי המבקש, וזוהי במהותה, למתן צו עשה זמני, דבר שאך יצריך קיום דיון נוסף ומיותר, שכן ניתן לקיים דיון זה כבר עתה.

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שבישור** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 214/12
מס' בקשה: 98/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700. עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה לאחר שהעבודות כבר בוצעו על ידי המשיבים בין מועד מתן צו המניעה (ביום 23.07.12) ועד למועד מסירתו לידם (ביום 25.07.12).

ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "ההלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. **צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים**, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653 - 654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו])" (ההדגשה שלי, א.ס.).

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים ולאור ההלכות האמורות לעיל, הגעתי למסקנה כי אין בנסיבות הבקשה דנן את אותו "מקרה יוצא מן הכלל" המצדיק מתן צו עשה זמני כמבוקש.

השתכנעתי כי בנסיבות דנן קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה כנדרש על פי התקנות – טענת המבקש כי העבודה המבוצעת ברכוש המשותף גורמת לו לנזק בלתי סביר הינה טענה המחייבת ברור עובדתי ומשפטי במסגרת התיק העיקרי.

אולם, לאור קיומה של הסכמה לכאורה של 7 מתוך 10 בעלי דירות בבית לביצוע העבודות ולאור העובדה כי אין מחלוקת שבנסיבות דנן חלות הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), הרי שבכדי שיהיה זכאי המבקש לסעד הזמני המבוקש עליו להראות כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן ברור, דבר שאינו מתקיים במקרה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 214/12
מס' בקשה: 98/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ראשית, הבקשה לא נועדה עוד כדי לשמור על המצב הקיים. אומנם, הבקשה המקורית למתן צו מניעה זמני הוגשה טרם ביצוע העבודות. אולם, משבוצעו כבר העבודות, ולא תוך הפרתו של צו המניעה (שטרם נמסר למשיבים בעת ביצוע העבודות), הרי שהמצב הקיים כיום הינו כזה לפיו ישנו כבר פתח כניסה לדירה בקומה הראשונה.

שנית, הסעד הזמני המבוקש זהה לחלוטין לסעד המבוקש בתיק העיקרי (סעיף 32.א. לכתב התביעה). קבלת הבקשה בהקשר האמור עלולה, במידה רבה, לייתר את המשך הדיון בהליך העיקרי או למצער ולהעמיס עלויות מיותרות על הצדדים. כך, אם תתקבל הבקשה דנן בעוד התובענה העיקרית תדחה הרי שבוצעו עבודות מיותרות לסגירת הפתח ויהיה צורך בפתיחתו מחדש.

אומנם, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לשלול מתן סעד זמני כשזה נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים המטים את כף מאזן הנוחות ושיקולי היושר לכיוון דחיית הבקשה (רע"א 4196/93 שפע בר נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

שלישית, בנסיבות דנן הנזק שיגרם למשיב 1 אם יינתן הסעד הזמני, גדול בהרבה מזה אשר יגרם למבקש אם לא יינתן הצו.

אין מחלוקת בדבר מוגבלויותיו הפיזיות של המשיב 1 ונכותו. אין גם מחלוקת כי הדלת שנפתחה נותנת פתרון למוגבלויות אלו (אף כי לטענת המבקש ישנם פתרונות אחרים). אם יינתן צו העשה הזמני כמבוקש, הרי שעד למועד ההכרעה בתובענה לא יוכל המשיב 1 לעשות שימוש בקומה העליונה של דירתו (בה ממוקמים חדר השירותים וחדר השינה) ומכך שאורחות ואיכות חייו היומיומיים וצרכיו האנושיים הבסיסיים יפגעו לאחר גמר השיפוצים בדירתו.

מאידך, למבקש לא יגרם כל נזק אם הפתח ייסגר רק לאחר דיון בתובענה העיקרית, ככל שזו תתקבל, ולא כבר בשלב מקדמי זה. ראשית, המבקש אינו גר בדירתו וזו מושכרת ולפיכך אין כל פגיעה או מטרד לשימוש האישי שלו בדירה או פגיעה באיכות חייו. שנית, טענת המבקש כי יגרם לו נזק בכך ששוכרת הדירה תעזוב, אין בה די כדי להטות את מאזן הנוחות - הטענה כי ניתן לראות בביצוע פעולות ברכוש המשותף על ידי אחר משום הפרה של הסכם שכירות הינה טענה דחוקה וממילא לא הוכחה בדבר, אפילו לא בהצגת הסכם השכירות. מכל מקום, אף אם כך הם פני הדברים הרי שהמדובר בנזק הניתן לכימות כספי ולשיפוי. שלישית, עיקר טענות המבקש הינן כי העבודות גורמות לנזק לקניינו. דא עקא, אין בקיומו של הפתח בתקופה שעד להכרעה בתיק העיקרי כדי להעצים נזק קנייני זה ככל שישנו, ומכל מקום, אף אם יגרם נזק כלשהו עד להכרעה בתובענה הרי שגם זה ניתן לכימות ולשיפוי.

וידוגש, ממילא עד לגמר ביצוע עבודות השיפוצים בדירת המשיבים אין כל צורך לשימוש בדלת האמורה שנועדה, על פי הצהרת המשיבים, אך לשם כניסתו של המשיב 1 לקומה העליונה בדירתו. משכך, נשללת למעשה כל פגיעה אפשרית במבקש בפרק הזמן שעד לגמר השיפוצים בדירת המשיבים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 214/12
מס' בקשה: 98/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בכל הקשור לשיקולי היושר הרי שלא ניתן להתעלם מן העובדה כי בבקשתו טוען המבקש באופן נחרץ וברור כי אין בידי המשיב הסכמה של איש מבין בעלי הדירות בבית (ראה סעיפים 10, 17, 20, 22 א, ג. לתצהיר המבקש). דא עקא, המשיב הציג בפני חתימתם של 7 מתוך 10 בעלי הדירות בבית לפיה הם מביעים את הסכמתם לעבודות. אף אם לא ידע המבקש על קיומן של חתימות ההסכמה האמורות, עדיין יוצא כי הצהרתו הגורפת, מספר פעמים בתצהיר המצורף לבקשה, היתה מוגזמת או למצער לא נבדקה כראוי טרם הגשת הבקשה ומסירת תצהירו.

אעיר כי גם לא התרשמתי כי המשיבים פעלו ב"מחשכים" להוצאת היתר הבניה או לביצוע העבודות. מן הבקשה עצמה עולה כי הודעות בדבר הגשת הבקשה להיתר נשלחו לבעלי הדירות בבית והמבקש עצמו אף הגיש התנגדות לבקשה להיתר. מן הצירופים לתגובת המשיבים עולה כי בין הצדדים נוהלו דברים כבר מחודש 12/10.

מאידך, על אף שהמבקש ידע כי התנגדותו לבקשה להיתר נדחתה ביום 29.03.12 (ואף הוגש על ידו ערר על החלטה זו ביום 17.05.12) ועל אף שההיתר הוצא ביום 12.07.12, את הבקשה דנן הוא הגיש רק ביום 23.07.12. בנסיבות אלו לפיהן הבקשה הוגשה כ- 4 חודשים לאחר דחיית ההתנגדות ולמעלה מ- 10 ימים לאחר מתן ההיתר, הרי שקיים שיהוי המצדיק את דחיית הבקשה למתן צו עשה. ויודגש, לו היה פונה המבקש במועד בבקשתו המקורית, הרי שהפתח טרם היה נפתח ולא היה נדרש דיון בבקשה למתן צו עשה זמני לסגירתו.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה למתן צו עשה זמני.

כאמור לעיל, למען הסר ספק, צו המניעה הזמני שניתן ביום 23.07.12 מבוטל.

הוצאות הבקשה דנן בסך של 1,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל ישולמו בהתאם לתוצאת התיק העיקרי. כך, אם תתקבל התביעה יישאו המשיבים בהוצאות הבקשה וישלמו את הסכום האמור למבקש. אולם, אם תדחה התביעה, ישלם המבקש את הוצאות הבקשה כאמור למשיבים.

המשיבים יגישו כתב הגנה בתיק העיקרי בתוך 30 יום.

נקבע לדיון בתובענה ליום 04.12.12 שעה 12:00.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלשכתי היום י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין